



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000815974

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001269-21.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante SIDNEI DA SILVA CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN SARTORI (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.

São Paulo, 19 de outubro de 2017

LAURO MENS DE MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelante(s): Sidnei da Silva Cardoso

Apelado(a)(s): Ministério Público do Estado de São Paulo

PRELIMINAR – nulidade – ausência de justa causa para deflagrar a ação penal – caso em que está presente a justa causa – recebimento da denúncia mantido – preliminar rejeitada.

LESÃO CORPORAL – materialidade – boletim de ocorrência e o laudo comprovam que foi ofendida a integridade corporal da vítima, ex-companheira do acusado em situação de violência doméstica e familiar.

LESÃO CORPORAL – autoria – vítima que confirmou ter sido agredida – restante da prova oral confirmando a prática delitiva.

AMEAÇA – materialidade – A prova oral confirma que foi ameaçada a vítima por meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

AMEAÇA – autoria – vítima que confirmou ter sido ameaçada – restante da prova oral confirmando a prática delitiva.

PENAS – lesão corporal – ausência de circunstâncias – pena no mínimo – ameaça – primeira fase – pena no mínimo – segunda fase – agravante relativa à violência doméstica – terceira fase – ausência de circunstâncias – continuidade delitiva, pois diversas as ameaças – concurso material entre a lesão e as ameaças.

REGIME – inicial aberto.

SURSIS – cabimento – manutenção da suspensão condicional da pena aplicada.

Ao relatório da r. sentença¹, proferida pelo Dr. Matheus Barbosa Pandino², que ora se adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no artigo 129, §9º, e artigo 147, *caput*, na forma do artigo 71, todos do Código Penal³, à pena de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto. Foi concedido suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 anos, com as condições especiais de não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 10 dias, bem como não alterar seu endereço

¹ Folhas 95.

² 2ª Vara da Comarca de Itapeva.

³ Fato ocorrido em 14/02/2015.

residencial, sem prévia autorização judicial, e de comparecer pessoal, e obrigatoriamente em Juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

O réu apelou⁴ alegando preliminarmente ter sido indevido o recebimento da denúncia por inexistir justa causa para a ação penal. No mérito pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, afastando-se a agravante imposta, com a fixação de regime aberto e aplicação de pena restritiva de direitos ou *sursis*.

Apresentadas contrarrazões⁵.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou⁶ pelo não provimento ao recurso.

É o relatório.

Da preliminar

Sustentou a defesa nulidade por ausência de justa causa para deflagrar a ação penal.

Entende-se por justa causa o lastro mínimo probatório necessário para iniciar-se a ação penal.

O recebimento da denúncia, quando ausente a justa causa, teria por finalidade tão somente obter-se a chamada “legitimação mediante o processo”.

Segundo tal entendimento, como afirma LUHMANN⁷, o processo seria utilizado para a parte aceitar um resultado desfavorável, que de outra forma não ocorreria.

Ou seja, embora fique patente desde o início que a demanda da parte não se encontra em consonância com o direito, utiliza-se o processo como forma de legitimação desta decisão.

⁴ Folhas 104.

⁵ Folhas 117.

⁶ Folhas 125.

⁷ *Legitimation durch verfahren*, Darmstadt Neuwied – 2ª ed. – 1975 – p.51.

A legitimação mediante o processo é “una resolución jurídica no se asienta en la “verdad” o la “justicia”, sino en um “proceso” acertado”⁸.

Assim, ainda que tal entendimento possa ser utilizado em matéria cível, não deve ser aplicado em matéria penal, visto que “en el proceso penal la posición del acusado es más peligrosa y, consecuentemente, más protegida que la posición de las partes litigantes del proceso civil”⁹.

Neste sentido, não se pode simplesmente atacar o direito da pessoa acusada a não sofrer qualquer sanção, sendo certo que o processo penal não deixa de ser um ônus, tão somente para que, no final, obtenha-se uma legitimação para sua absolvição, cuja solução se mostra desde o início.

O fato de tratar-se de bem jurídico relevante, a vida humana, também não autoriza tal solução.

O direito penal é um tema político por excelência, visto que nele ocorre o conflito entre o indivíduo e a autoridade estatal.

Como afirma FRANCESCO C. PALAZZO¹⁰, “*existe uma intrínseca e específica politicidade do direito penal que deriva ou da absoluta falta de qualquer espaço de autonomia privada ou da natureza privada ou da natureza da soma de bens que este se propõe a tutelar com o aguçado instrumento da pena criminal. Teme-se, em razão disto, o perigo da tentação de um “abuso político” do direito penal*”.

E isto que ocorre quando se permite o processo apenas como instrumento de legitimação, expondo a pessoa acusada ao processo que desde o início se sabe ser desnecessário, ignorando-se o valor originário e supremo que é o homem, que passa a ser reduzido a uma simples expressão de um sistema de justiça e de uma ordem de valores tidos absolutos só porque impostos pelo Estado ou, como afirma PALAZZO, “*expressão de uma filosofia utilitarista que não hesita em instrumentalizar o homem – programando, verdadeiramente, a transformação de sua personalidade – para evitar o cometimento de novos ilícitos (a punição ne peccetur)*”, usando o processo como pena e com

⁸ Hassemer, Winfried. *Fundamentos del derecho penal* – Barcelona: Bosch– 1984 – p. 125.

⁹ Hassemer, Winfried. *Ob. Cit.* – p. 126.

¹⁰ *Valores constitucionais e Direito Penal.* – Sérgio Antonio Fabris Editor – 1989 – p.17.

ela atingindo a prevenção geral e específica.

Dentro de um Estado de Direito Democrático não se permite a transformação do homem a um instrumento, desconsiderando-se seus direitos inerentes a todo o ser humano, para usá-lo como exemplo da violência simbólica utilizada pelo Estado, ferindo seu “*status dignitatis*”, e servido para atemorizar terceiros e legitimar a existência do Estado em face deles.

A dignidade do homem pode sofrer prejuízos impostos pelo Estado, por meio de processo penal, desde que exista *fumus bonni iuris*, como afirma JOSÉ FREDERICO MARQUES ¹¹.

O ponto a ser enfrentado versa acerca do conteúdo dessa fumaça do bom direito. Ou seja, basta prova de crime e indícios de autoria, ainda que tais indícios mostrem-se insuficientes para um decreto condenatório?

Qual seria, portanto a finalidade do processo, como já exposto acima. Servir de legitimação para terceiros, utilizando-se o Estado dele como forma indireta de coerção?

Assim, para o recebimento da denúncia devem existir provas que gerem certeza, visto que os eventuais fatos contrários foram suplantados por elas, dentro de um complexo de motivos consagrados pela razão e pela experiência, indicando a real possibilidade de procedência, sem o que não se vislumbra a possibilidade de sacrificar a dignidade humana por meio do processo penal acusatório.

Conclui-se, utilizando-se os ensinamentos de JOSÉ FREDERICO MARQUES ¹², no sentido de que “*é preciso que haja fumus bonni iuris para que a ação penal contenha condições de viabilidade. Do contrário, inepta se apresentará a denúncia, por faltar legítimo interesse e, conseqüentemente, justa causa. Imperativo é, por isso, o controle do juiz sobre essa condição de viabilidade do pedido acusatório, pois, se assim não for, pode ser atingido, indevidamente, o status libertatis do acusado. Não há, no caso, um juízo de formação de culpa, com apuração rigorosa do corpo de delito. O que existe é um despacho de deliberação, provisório e*

¹¹ Vide *Estudos de Direito Processual Penal*. – Millennium – 2001 – p. 142-146.

¹² *Elementos de Direito Processual Penal*. – 2ª ed – Millennium – 2000 – p. 200-201.

simples, em que o juiz apura se há aquela fumaça de bom direito que autoriza a instauração da persecutio criminis em sua fase processual. O processo penal atinge o status dignitatis do acusado. Em vários casos, este sacrifício é exigido (como acontece sempre que o réu é absolvido) no interesse do bem comum. Todavia, se nem o fumus boni iuris pode descobrir-se, para alicerçar a peça acusatória, seria iníquo que o juiz permanecesse impassível e, como simples autômato, fosse recebendo a denúncia ou queixa”.

Neste sentido tranquilo o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a acusação somente é viável quando houver provas, ao menos indiciárias para ampará-la.

No caso em tela há indícios suficientes a justificar a deflagração da ação penal, vez que a vítima ao ser ouvida na fase policial confirmou ter sido ameaçada por seu ex-companheiro, pois este lhe disse que a mataria. Narrou também ter sofrido agressão física¹³. Deste modo, escorreito o recebimento da denúncia.

Portanto, rejeito a preliminar.

Da lesão corporal

O boletim de ocorrência¹⁴ e o laudo¹⁵ comprovam que foi ofendida a integridade corporal da vítima, ex-companheira do acusado em situação de violência doméstica e familiar. Patente, portanto, a materialidade delitiva.

Quanto à autoria, o acusado Sidnei embora intimado, não compareceu, tendo sido decretada sua revelia¹⁷.

A vítima Jaqueline¹⁸ em juízo disse que tem um relacionamento amoroso com o réu e que no dia dos fatos, iniciou-se uma discussão por conta de uma mensagem no celular. O réu grudou em seu braço e sacudiu. O réu ficou irritado por ela ter mexido em seu celular. Devido a isso, ambos se alteraram. O réu deu-lhe chutes, tapa no rosto e torceu-lhe o braço. Tentou agredi-lo

¹³ Folhas 34.

¹⁴ Folhas 27.

¹⁵ Folhas 23.

¹⁷ Folhas 93.

¹⁸ Mídia.

também, empurrando-o, mas não chegou a agredir o réu. No meio da discussão, o réu pegou uma faca e disse que se mataria ou então a mataria, encostando a faca em seu pescoço. Após, o réu se acalmou e guardou a faca e ela ficou chorando no quarto. Após, rompeu a relação e foi morar com sua mãe, porém no dia seguinte, o réu foi atrás dela e a ameaçou e agredindo-a, segurando-lhe o braço. Na ocasião, chegou a pedir por socorro. Tempos depois, o réu, que continuou a ter contato com ela, pegou seu celular e se alterou. Foi conversar com o réu na praça da Escola Otávio e acabaram discutindo e o réu a ameaçou, dizendo que ela teria de voltar com ele de qualquer forma, ameaçando-a de morte. Nessa ocasião, o réu havia tomado uma estrada de terra, dizendo que iria se matar, mas que também a mataria. A discussão terminou porque a testemunha Mônica Delgado de Moraes acabou ligando e o réu a levou para casa. Atualmente, vivem bem. Não chegou a se sentir ameaçada pelo réu quando ele pegou a faca, pois o conhece. Também não se sentiu ameaçada quando o réu a levou a lugar ermo.

A ofendida confirmou ter sofrido agressões físicas e ter sido ameaçada por inúmeras vezes. Ainda que ao final tenha dito que não se sentiu ameaçada, tal ponto deve ser visto com reserva, pois claramente a vítima busca resguardar o réu, já que quando de suas declarações estavam juntos. De todo modo, confirmou ter sido agredida.

A testemunha Mônica Delgado de Moraes²⁰, em juízo, disse que se lembra dos fatos, porém, não presenciou os fatos. Soube quando a vítima telefonou, pedindo ajuda. Não sabia que o réu havia agredido a vítima. Chegou a ver a vítima entrando no carro, mas não suspeitou de nada anormal. Quando a vítima ligou, ambos estavam gritando. Após, o réu levou a vítima para casa. Dias após a briga, o réu ligava para ela dizendo que iria matar a vítima, falando vou matar ela, vou botar fogo. Nestas ocasiões, o réu assegurava que estava na frente da casa da vítima e não chegavam nem a dormir. A vítima ficou abalada e no auge dos fatos, a vítima estava muito temerosa, pois o réu a perseguia constantemente e ela não sabia o que esperar dele.

Referida testemunha confirmou a

²⁰ Mídia.

agressão física perpetrada pelo acusado.

A testemunha Vera Lúcia de Souza Carvalho²¹ alegou em juízo que é mãe da vítima, que no dia das agressões houve discussão por contra de ciúmes do réu. Após a separação, o réu ficava em frente à sua casa e falava que iria matar a vítima. O réu passava diversas vezes em frente à sua casa e ele não aceitava o fim do relacionamento. O réu a perseguiu, mas a vítima não tinha receio do réu.

A mãe da vítima também confirmou a agressão sofrida.

Portanto, ante a prova oral colhida, de rigor a comprovação da autoria delitiva.

Da ameaça

A prova oral confirma que foi ameaçada a vítima por meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave. Patente, portanto, a materialidade delitiva.

Quanto à autoria, a vítima confirmou ter sido ameaçada de morte pelo acusado, o que fez inclusive com auxílio de uma faca, sendo que a ameaça se deu em outras ocasiões também.

Não há que se falar em efetiva ausência de temor por parte da vítima. Tanto a postura do réu a intimidou que após o ocorrido se separou do réu e foi viver com sua mãe.

Do mesmo modo, as testemunhas Mônica e Vera confirmaram as ameaças perpetradas pelo acusado.

Portanto, ante a prova oral colhida de rigor a comprovação do delito de ameaça.

Passemos a análise das penas.

Em relação ao delito de lesão corporal, à

²¹ Mídia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

míngua de circunstâncias nas três fases, a pena foi fixada no mínimo legal, em 03 meses de detenção, o que mantenho.

Em relação ao delito de ameaça, na primeira fase à míngua de circunstâncias mantenho a reprimenda em 01 mês de detenção. Na segunda fase presente a agravante da violência doméstica a pena foi dobrada, sendo fixada em 02 meses de detenção, o que mantenho. Por fim, na terceira fase, à míngua de circunstâncias, mantenho a reprimenda tal como fixada. Em sendo diversas as ameaçadas, foi aplicada a continuidade delitiva e majorada a pena em um sexto, sendo fixada em 02 meses e 10 dias de detenção, o que mantenho.

Entre ambos os crimes aplicou-se o concurso material, somando-se as penas e obtendo-se o final de 05 meses e 10 dias de detenção.

Fixou-se o regime aberto, o que não demanda reparos.

Incabível a aplicação de pena restritiva de direitos por se tratar de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça.

Contudo, cabível o *sursis* que foi fixada, de modo que o mantenho pelo prazo de 02 anos estabelecido na r. sentença com as condições ali estabelecidas.

Ante o exposto, **REJEITO A PRELIMINAR** e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

LAURO MENS DE MELLO

Relator

Assinatura Eletrônica